

1500393-66.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... (com o réu), que se destinavam mesmo ao tráfico. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de venda para a configuração do tráfico.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500393-66.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500393-66.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2125541/2021 - 01º D.P. AMERICANA,

17797577 - 01º D.P. AMERICANA, 2125541/2021 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 683/21/344 -

DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ WAGNER DO NASCIMENTO BISPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

JOSÉ WAGNER DO NASCIMENTO BISPO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06, acusado de no dia 09 de maio de 2021, por volta de 03h32, na Avenida Doutor José Barreto Pinto, 352, bairro São Benedito, nesta cidade, trazer com ele, para fins de tráfico, 18 (dezoito) micro tubos de cocaína, pesando aproximadamente 2,47 gramas, além de R\$ 10,00, drogas prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação. A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 157/158) e o réu foi citado (fls. 174).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 187/191).

A Defesa reclama a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. O réu não foi surpreendido em situação de venda e portaria quantia inexpressiva. Os guardas civis não o surpreenderam com entorpecentes anteriormente. Não havia denúncia envolvendo o acusado. Era usuário e frequentador assíduo de pontos de vendas de drogas desde a adolescência. Invocava a presunção de sua inocência. Para o caso de condenação, pela primariedade, pena mínima, com reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Não se dedicava a atividade criminosa e nem integrava organização criminosa. Faria jus à substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime brando e recurso em liberdade (fls. 195/201).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Verifica-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito e na fase administrativa permaneceu em silêncio.

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Em Juízo, alegou que era usuário de drogas e estava indo comprar entorpecentes. Os guardas perguntaram sobre o valor que trazia no bolso, R\$ 10,00 e a eles já havia dito que iria comprar drogas. Eles sabiam de seu vício e já o haviam abordado anteriormente. Um deles ficou em sua companhia, enquanto os outros guardas dispersaram. Após vinte minutos, retornaram com algo que nem sabia o que seria. Simplesmente foi algemado e colocado na viatura.

Questionou os motivos pelos quais estava sendo preso, mas nada disseram. A abordagem ocorreu às 03h25. Trabalhava como ajudante de pintura, carpia terrenos ou pedreiro. Não tinha nada fixo. Não tinha drogas em seu poder, os guardas não acharam 18 micro tubos de entorpecentes nas suas vestes. Não sabia por que estava sendo preso. Nem chegou a ver as drogas. Falou para o Delegado que não sabia o motivo de sua prisão. Disse para os policiais que estava indo na biqueira para comprar drogas. Não apontou o local nem a pessoa de quem compraria os entorpecentes. É usuário de drogas desde os quinze anos de idade. Foi submetido a tratamento no CAPS de Americana, por iniciativa própria. Já foi internado em clínica de reabilitação para tratamento. Trabalhava registrado como ajudante geral em uma fábrica de pão. Na época dos fatos, era autônomo. Na data, havia recebido a

quantia de R\$ 60,00 por um 'bico' que havia realizado. Costumava pegar entorpecentes nas proximidades do local em que foi abordado. Já tinha sido abordado pelos mesmos guardas municipais anteriormente. Em todas as ocasiões, foi agredido. Eles tinham conhecimento de que era usuário de drogas.

A prova oral o incriminou, contudo.

A testemunha guarda municipal Clóvis Alves de Souza, recordou-se de que patrulhavam pela via quando avistaram o suspeito atravessando o canteiro central da rua. Foi em direção a mais três homens. Resolveram fazer a abordagem porque o suspeito era conhecido da equipe pela prática do tráfico no local. Durante a revista, localizaram nas vestes do acusado dezoito pinos, aparentando ser cocaína, além da quantia de R\$ 10,00. Nada de ilícito foi encontrado com os outros três rapazes, que foram liberados no local. Diante dos fatos, o réu foi apresentado na Central de Polícia Judiciária.

José Luciano Salvato, outro guarda, ratificou a versão em uníssono, harmônica e coerentemente. Destacou que patrulhavam pela Rua Doutor José Barreto Pinto, quando avistaram o suspeito atravessando a rua. No meio fio, havia mais três homens sentados. Como conheciam o suspeito de abordagens anteriores e o local era conhecido pela venda de drogas, aproximaram-se com a viatura e os abordaram. Durante a revista, nada de ilícito foi localizado com os rapazes que estavam sentados. Com José, encontraram dezoito porções de cocaína em seu bolso e a quantia de R\$ 10,00.

Diante dos fatos, conduziram o acusado até o Plantão Policial para lavratura do auto de prisão em flagrante. Não se recordava se o réu tinha sido abordado uma semana antes, mas o conhecia de abordagens anteriores. Lembrava-se de outra prisão que realizou na mesma rua, um pouco mais à frente. Na ocasião, um rapaz traficava e percebeu que José encostou para entregar ou pegar algo, mas ele saiu correndo. Esse episódio não foi isolado. O réu nada alegou. Não se recordava de ter perguntado sobre a destinação da droga, para o acusado. Ele estava acompanhado das três pessoas sentadas no meio fio.

A testemunha de Defesa Maria Zilce do Nascimento Bispo, genitora do acusado, esclareceu que José era usuário de entorpecentes desde os dezessete anos de idade. Seu filho fez tratamento no CAPS local, no ano 2019, por iniciativa própria. No ano de 2011, juntamente com a filha mais velha, conseguiram internar José em Clínica de Reabilitação, por conta da dependência química. O réu trabalhava com registro em carteira. Anteriormente, ele exercia serviços autônomos como pintor, capinando ou trabalhava como servente.

Como se vê, os guardas municipais, que tinham o local como ponto de tráfico, visualizaram o acusado, já conhecido da equipe, juntamente com outras pessoas. Revistado, localizaram nas vestes do acusado, dezoito micro tubos de cocaína, além da importância de R\$ 10,00, sem que o réu, prontamente ou a qualquer tempo, justificasse a lícita procedência.

A quantidade da droga, embora não expressiva, estava embalada individualmente e juntada em kit, propício para a venda, a par de ser mantida ocultada pelo réu, nas vestes.

Enfim se conclui, pela prova testemunhal, quantidade-nocividade da droga e forma de embalagem, acompanhada de numerário (com o réu), que se destinavam mesmo ao tráfico. Idem para o numerário, sem procedência lícita provada, em ponto de tráfico.

O auto de exibição e apreensão confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de venda para a configuração do tráfico.

Na doutrina:

“Nota-se facilmente que o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, isto é, possui várias condutas típicas separadas pela conjunção alternativa “ou”. Em razão disso, a pluralidade de condutas envolvendo o mesmo objeto material constitui crime único. Exemplo: adquirir, transportar, guardar e depois vender a mesma substância entorpecente. Nesse caso, há um só crime, porque

as diversas condutas são fases sucessivas de um mesmo ilícito. Os crimes de ação múltipla são também chamados de crimes de conteúdo variado ou de tipo misto alternativo. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, é suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo desnecessária a realização de atos de venda do entorpecente." (Victor Eduardo Rios Gonçalves, 2020, pág.87, Legislação Penal esquematizada).

E na jurisprudência:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização" (RT 714/357).

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

O fato de o réu também ser usuário de drogas, evidentemente, não exonera a conduta, antes tem por absorvido, o porte de drogas para uso, pelo tráfico ora reconhecido. A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo de constatação (fls. 12/14), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 123/125).

Bem típica a conduta, pois, que merece severa punição.

Fixação das penas.

O réu é primário. A quantidade de drogas era normal para o tipo de infração, tráfico. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Mantenho inalterada a pena base, fixada no mínimo.

Na terceira fase, pela não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de metade, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida (18 porções de cocaína).

Possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecido o tráfico privilegiado e a somatória final da pena, com estipulação do regime aberto para o caso de revogação.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.” HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”: Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, o regime inicial aberto, analisada a detida conduta dos autos, é de ser imposto ao condenado, primário.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar JOSÉ WAGNER DO NASCIMENTO BISPO, às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e par. 4º, da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo. Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Condeno o réu nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, na medida em que constituiu advogada, sem comprovação de que fosse hipossuficiente.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 18 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA